

1501743-88.2022.8.26.0619

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Matheus de Souza Parducci Camargo

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 4ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... nos meios policiais por promover o tráfico de drogas, bem como o local em que ele estava é conhecido por ser ponto de venda de drogas. Da prova oral colhida constata-se que na data e local dos fatos o réu praticava o tráfico de drogas não havendo dúvidas acerca da subsunção fática ao tipo penal imputado na exordial. Demais disso, não cabe falar em desclassificação para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

4ª Vara Judicial

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-017, Fone: (16)3252 5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga4@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL (TELEAUDIÊNCIA)

Processo Digital nº:

1501743-88.2022.8.26.0619

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ELTON LUIZ DA SILVA

Data da Audiência:

08/12/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 08/12/2022, às 15:00h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 4ª Vara Judicial, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Matheus de Souza Parducci Camargo, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência Virtual de Instrução, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM 2549/2020, Comunicado CG de nºs 250/2020 e 284/2020, todos deste Eg. TJSP; Recomendação CNJ 62/2020; bem como Decreto Estadual 64.879/2020. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, ao ato processual, sob a concordância de todos, anuência esta estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Prévia e separadamente, reuniram-se o acusado e seu defensor por meio de reunião paralela, no próprio Teams. Após, instalou-se formalmente a telaudiência. Verificou-se a presença virtual do DD. Representante do Ministério Público, Dr. ILO WILSON MARINHO GONÇALVES JÚNIOR; do acusado ELTON LUIZ DA SILVA e do seu Defensor Nomeado, Dr. LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA, OAB/SP 197.828. Presentes, ainda,

virtualmente, as testemunhas de acusação DURVAL JESUS DE SOUZA e SERGIO ADRIANO DELLAPINA. Iniciados os trabalhos, passou o MM. Juiz a colher o depoimento das testemunhas de acusação acima nominadas. A, seguir, o réu foi interrogado. Os depoimentos das testemunhas foram tomados sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A mídia digital ficará mantida em computador deste Juízo, em pasta apropriada para armazenamento e compartilhamento. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que não havendo mais provas a produzir, dava por encerrada a instrução passando aos debates orais. Dada a palavra ao DD. Promotor para as alegações finais, pelo mesmo foi dito: "MM Juiz, O(s) réu(s), em epígrafe, foi (ram) denunciado(ram) e está sendo processado(s) como incurso(s) no(s) art. 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06, tudo nos termos do narrado na exordial acusatória. O(s) acusado(s) foi(ram) notificado(s) e citado(s) e apresentou(ram) resposta à acusação, com posterior recebimento da denúncia. Nesta oportunidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como procedido ao(s) interrogatório(s). Encerrada a persecutio criminis in judicio o Ilustre Magistrado determinou que as partes apresentassem alegações finais neste momento. É o sucinto relatório. Não há preliminares ou potenciais causas de nulidade acerca da tramitação do feito, sendo certo que a relação jurídica processual, desenvolveu-se de maneira escorreita, razão pela qual adentro ao mérito. Impõe-se a condenação dos(as) acusados(as). A materialidade dos crimes está positivada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 107), laudo toxicológico definitivo (fls.116/118). A autoria do(s) crime(s) descrito(s) na exordial é inquestionável. O réu ao ser interrogado na DEPOL às fls. 06 disse que iria usar uma pedra de crack, desconhecendo a lata de crack encontrada pelos policiais. Em juízo, afirmou que apenas foi pegar uma pedra de crack no dia dos fatos, quando a viatura subiu na contramão e o traficante fugiu e vieram apenas atrás do interrogando e acredita que isso seja uma perseguição do policial Delapina. A testemunha Durval Jesus de Souza, policial militar, ouvida em solo extrajudicial e nesta oportunidade, que estavam em patrulhamento no Jardim Micali, e quando trafegavam pela Rua Professor Paulo Lazaro Mendes Ferreira, cruzamento com a Rua 4, avistaram o indiciado. Quando o indiciado avistou a viatura policial ele se demonstrou apreensivo. Por ser o indiciado conhecido nos meios policiais foram efetuar a abordagem dele. Assim que deram ordens ao indiciado para procederem a abordagem, o indiciado saiu correndo. O depoente passou a fazer o acompanhamento a pé, ao passo que o seu parceiro foi com a viatura. Enquanto o indiciado se evadia ele dispensou uma embalagem de lata. O depoente pegou a embalagem e continuou fazendo o acompanhamento. Após aproximadamente uns quinhentos metros, o parceiro do depoente, que estava com viatura conseguiu abordar o indiciado. Assim que se aproximou do indiciado e constataram que na embalagem de lata que ele descartou havia 29 pedras de crack foi dada voz de prisão a ele. Como ele já havia se evadido foram algema-lo, momento que o indiciado não deixou ser algemado. Foi necessário fazer o uso da força para conte-lo. Devido a necessidade de fazer força para conter o indiciado ele acabou ficando com escoriações nos pés. O denunciado é conhecido por promover o tráfico de drogas, bem como o local que ele estava é conhecido por ser ponto de venda de drogas. A testemunha Sérgio Adriano Dellapina, apresentou depoimento no mesmo sentido, afirmando que trafegavam pela Rua Professor Paulo Lazaro Mendes Ferreira, cruzamento com a Rua 4, avistaram o indiciado. O indiciado demonstrou-se apreensivo ao visualizar a viatura policial, e por ser conhecido nos meios policiais foram efetuar a abordagem dele. Quando foi dado ordens necessárias para a abordagem de forma segura para todos o indiciado saiu correndo. O depoente adentrou na viatura e fez o acompanhamento, enquanto seu parceiro fez o acompanhamento a pé. Enquanto o indiciado se evadia, o parceiro do depoente avistou ele dispensando uma embalagem de lata. Quando conseguiu efetuar a abordagem do indiciado, efetuada busca pessoal com ele não havia nada de ilícito. Ao verificarem o que havia no interior da embalagem de lata que ele dispensou, constatou que se tratava de 29 pedras de crack. Foi dada voz de prisão para o indiciado. Como ele já havia se evadido foram algema-lo, momento que o indiciado não deixou ser algemado. Foi necessário fazer o uso da força para conte-lo. Devido a necessidade de fazer

força para conter o indiciado ele acabou ficando com escoriações nos pés. O indiciado já é conhecido nos meios policiais por promover o tráfico de drogas, bem como o local em que ele estava é conhecido por ser ponto de venda de drogas. Da prova oral colhida constata-se que na data e local dos fatos o réu praticava o tráfico de drogas não havendo dúvidas acerca da subsunção fática ao tipo penal imputado na exordial. Demais disso, não cabe falar em desclassificação para consumo pessoal (art. 28, da Lei de Drogas) como pretende o acusado ao afirmar em seu interrogatório que a droga se destinava ao uso próprio. Anoto, em acréscimo, que não há se confundir o tráfico com o propósito do uso pessoal. O art. 28, § 2º da Lei nº 11.343/06 traz os critérios legais a serem sopesados nessa classificação. Cotejando-os, anoto apontarem o destino de tráfico das porções apreendidas com o denunciado os seguintes elementos: a quantidade de drogas apreendida; sua natureza e forma de acondicionamento, já que estava dividida em porções individuais prontas para comercialização; as denúncias anônimas recebidas; as circunstâncias do flagrante; entre outros. No caso presente, portanto, a tese de uso próprio é infundada, eis que nítido o propósito de traficância. Os elementos já destacados indicam, com firmeza, não se tratar de mero usuário de drogas. Conforme explicado por Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, "em geral, a quantidade de droga, notadamente em vista de sua natureza, poderá ser indicativa de mercancia. De outro lado, a forma de acondicionamento da droga (por exemplo, se embaladas para venda), o local (se próximo a pontos conhecidos como distribuição da droga, por exemplo) e horário da apreensão, assim como as demais circunstâncias em que se desenvolveu a ação (o porte de valores significativos de dinheiro, recebidos dos usuários) devem ser alguns dos critérios norteadores do magistrado" (Lei de Drogas, 3ª ed., Método, 2013, nº 3.4.1.1, pág. 56, grifei). Cito, por oportuno, entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "TRÁFICO. Destinação a terceiros. Indícios tais como quantidade e variedade incompatível com a figura de usuário; a forma de acondicionamento em porções, próprias para a venda a varejo; o dinheiro; o fato de ter sido surpreendido em atitude típica de traficância em local conhecido pelo comércio de drogas." (Apelação nº 0014475-90.2012.8.26.0405, 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO, j. 04/07/2013). Ademais, deve-se observar que a alegação de uso não tem o condão de, por si só, evitar condenação pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33 da Lei de Drogas. Até porque não é incomum a figura do usuário-traficante, até para sustentar o próprio vício. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, no julgamento da Revisão Criminal nº 0142902-25.2013.8.26.0000, 8º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Pedro Menin, j. 06 de fevereiro de 2014, entendeu que "como é sabido, mesmo sendo o agente usuário de drogas, isto não impede que seja, também, traficante, sendo comum usuários comercializarem drogas justamente para obter dinheiro para sustentar o vício. Nessa esteira: "Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados" (RT 411/104)". Na espécie, portanto, os elementos acima deduzidos indicam, com segurança, que a droga não se destinava ao consumo pessoal do denunciado mas sim para a entrega a consumo de terceiros. Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico não é necessário que o infrator

seja colhido comercializando a substância entorpecente, bastando, apenas, a comprovação de sinais indicativos do exercício da atividade delituosa. É o que se vê do seguinte excerto extraído do julgamento da Apelação nº 0000166-49.2013.8.26.0334, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. PENTEADO NAVARRO, j. 26 de junho de 2014, "a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico (cf. Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi, Lei de Drogas Anotada, 1ª ed., Saraiva, 2007, art. 33, nº 4, pág. 81; RTJ, 149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536, 793/576, 793/727, 807/597, 810/578 e 831/614). Daí segue ser dispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando a prova do conjunto de indícios e presunções (=circunstâncias ligadas ao fato

probando) envolvendo o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (= praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano (CPC, art. 335). Aliás, a questão em exame comporta a aplicação analógica das normas aludidas (art. 48 da Lei c/c art. 3º do CPP). Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (...)" . Por oportuno, "O tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. Além do mais, para tanto, basta também atentar para a incriminação do fornecimento (Precedentes). II - O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio. (Precedentes)" (STJ REsp nº 1133943/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 17/05/2010). Demais disso, as palavras dos agentes de segurança são harmônicas e encontram fundamento no conjunto probatório. Assim, se não há nada nos autos capaz de desabonar as seguras e coerentes declarações dos agentes de segurança não se provando que fossem desafetos do agente delitivo ou contra ele tivessem hostil prevenção, ou ainda quisessem perversamente prejudicá-lo é de ser decretada a condenação nelas baseada, até menos em homenagem ao trabalho daqueles que colocam suas vidas em risco pela segurança da coletividade. Como ensina a prelibada doutrina de Guilherme de Souza Nucci defende a validade dos depoimentos de policiais afirmando que: (...) preceitua o art. 202 do CPP que toda pessoa pode ser testemunha, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho. (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais comentadas, 2ª edição, São Paulo. Editora: Revista dos Tribunais, 2007. página 323). Ademais, as palavras das testemunhas, agentes de segurança, são provas fartas da ocorrência do crime, sendo unívocas e cristalinas, sendo certo que revestem-se, salvo prova em contrário, de legitimidade e veracidade quando ao conteúdo relatado, pois como preleciona a jurisprudência pátria: O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos(STF - HC 74.608-0/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 18. 02. 97 - DJ 11. 04. 97). E ainda: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO -PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas -Réu preso em flagrante transportando grande quantidade de droga - Confissão da posse da droga - Depoimento do policial confirmando a apreensão dos entorpecentes com o réu - O depoimento de policial tem validade como o de qualquer outra testemunha - Relato que se mostra coeso com as demais provas colhidas - Condenação mantida - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - Comprovação de que a droga se destinaria à mercancia - Alegação de viciado não obsta o reconhecimento do tráfico - Réu que não dispunha de recurso financeiro para o armazenamento de todo o entorpecente para futuro consumo - Quantidade de droga e forma de acondicionamento demonstram a intenção da mercancia - Outras delações aos policiais já davam conta que o réu vendia drogas no local - Sentença recorrida confirmada - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJSP Recurso de Apelação de nº. 990.10.167.209-0 - Rel. Dês. Amado de Faria, julgamento em 29/09/11).O auto de exibição e apreensão colacionado aos autos espelha fielmente as palavras dos Policiais. O(a) acusado(a) foi preso em circunstâncias que não deixam dúvidas sobre a prática do tráfico: fugindo à abordagem policial; informações anônimas dando conta de que o denunciado traficava na região; versão firme e coerente dos policiais e considerável quantidade de drogas, dinheiro sem origem lícita; tudo autoriza o reconhecimento da prática do delito objeto de apuração. A negativa do(a) acusado(a) restou isolada nos autos, sem nenhum fundamento. O laudo de exame toxicológico juntado aos autos confirma que as substâncias encontradas com o(a)

réu(ré) se tratam de drogas. Nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas, aquele que tem em depósito e guarda ou transporta, com o intuito de venda, drogas é traficante. Com relação à quantidade, irrelevante se mostra para fins de reconhecimento do delito a droga apreendida, eis que o bem jurídico penalmente tutelado não é apenas o bem estar do usuário, mas sim a saúde pública, que fica exposta a perigo concreto e iminente com a simples possibilidade da difusão do entorpecente, independentemente da sua maior ou menor quantidade, não se podendo perder de vista também que uma pequena quantidade pode ser o saldo de uma grande. Por derradeiro, caso seja alegada, saliento ainda que eventual requerimento de causa de diminuição em virtude de semi-imputabilidade decorrente de vício em substâncias entorpecentes não deve prosperar, pois aplicado perfeitamente no caso o princípio da actio libera in causa. Com efeito, o acusado, caso alegue ter praticado o delito em razão do vício em substâncias entorpecentes, se colocou, sponte propria, ao tempo da ação em nesta situação, a qual não pode ser usada para mitigar sua responsabilidade penal. Segundo leciona Mirabete "pode ocorrer que o agente se coloque, propositadamente, em situação de inimputabilidade para cometer o crime, realizando este no estado de insciência, drogando-se, embriagando-se, ou mesmo dormindo. Nesse caso, para o juízo de culpabilidade, considera-se a situação do agente no momento em que se colocou em estado de inconsciência, e não no momento da ocorrência do fato. Aplica-se, então, o princípio das chamadas actiones liberae in causa sive ad libertatem relatae, respondendo o agente pelo resultado. Esse princípio foi estendido às situações criadas culposamente pelo agente" (Código Penal Interpretado, 7ª ed., Ed. Atlas, 2011). Não há nos autos, elementos concretos de que a drogadição tenha lhe causado doença mental, apta a retirar-lhe ou diminuir-lhe a imputabilidade. Ademais, o art. 45 da Lei nº 11.343/2006 é certo ao prescrever que o reconhecimento da inimputabilidade por conta de dependência de drogas somente ocorrerá quando esta decorrer de caso fortuito ou força maior. Diz o indigitado preceito legal: Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (nosso grifo). Vale trazer à baila os exemplos de Guilherme de Souza Nucci acerca das condições que ensejam o afastamento da culpabilidade pela drogadição, nos moldes do art. 45 da Lei de Drogas: "caso fortuito seria a ingestão de droga, proveniente do engano, do logro, do erro (ex.: o sujeito toma uma determinada bebida, que contém certo tipo de droga não aparente, enganado por terceiro, ficando completamente incapacitado para entender o que faz). Força maior seria a ingestão da substância entorpecente por atuação física superior, externa à vontade do agente (ex.: injeta-se cocaína em alguém, que se encontra amarrado ou seguro por outras pessoas mais fortes, fazendo com que perca a capacidade de atendimento)" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª ed., 2011, RT.). No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria: APELAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE.APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 46 DA LEI Nº 11.343 /06. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME. ISENÇÃO DAS CUSTAS. DEFENSOR DATIVO. - Se há provas de que o réu cometeu o crime, a condenação é medida que se impõe. - Deve ser decotada a majorante do emprego de arma de fogo, se os elementos dos autos demonstram que a arma, no momento da prática do crime, não tinha aptidão para efetuar disparos. - Inexistindo comprovação de que o réu estava sob o efeito de drogas, no momento da prática criminosa, bem como de que a ingestão dos entorpecentes se deu em razão de caso fortuito ou força maior, é incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei no 11.343 /06. - Fixa-se o regime prisional aberto aos condenados, não reincidentes, a pena inferior a 4 (quatro) anos. - Cabe isentar do pagamento das custas processuais o réu, desde que assistido por Defensor Dativo, com base no art. 10 da Lei estadual nº 14.939/03. TJ-MG - Apelação Criminal APR 10058120007420001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 18/03/2013. Não há nos autos qualquer menção aos requisitos legais acima invocados (caso fortuito ou força maior), razão pela qual tal tese, caso invocada, deverá ser afastada. Há provas suficientes para a condenação razão pela qual a denúncia deve ser julgada procedente. Passo a analisar a necessária

fixação da pena e do regime penitenciário a ser adotada por este ínclito juízo. Na primeira fase de aplicação da sanção, ao magistrado é concedida ampla discricionariedade, regrada diga-se, dentro dos limites mínimo e máximo para a fixação da pena base. Assim, considerando todos os elementos previstos no artigo 59 do Código Penal que se amoldem ao caso concreto, deve o juiz, analisando as circunstâncias judiciais, fixar a pena base mais condizente com a realidade fática dos autos. Nessa esteira, entende a prelibada lição de Mirabete que: "Trata o art. 59, caput, e seus incisos I e II, da fixação da pena-base como primeira etapa da aplicação da pena privativa de liberdade, ou seja, a da pena-base entre os limites da sanção fixados abstratamente na lei penal, determinando que seja ela estabelecida conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sendo a culpabilidade do agente a base fundamental para a individualização da sanção a ser aplicada ao caso concreto, a reprovabilidade de sua conduta deve ser aferida para a fixação da pena-base. Refere-se, portanto, o caput do art. 59, às circunstâncias, chamadas de judiciais pela doutrina, que são os fatores dessa fixação". (MIRABETE, JÚLIO FABBRINI, in Código Penal Interpretado, 5ª edição, 2005, Editora Atlas, pág. 440). Neste contexto, podemos dizer que em relação à culpabilidade, nota-se que o(s) acusados(as) agiu(ram) com excesso de reprovabilidade, disseminando na sociedade o terrível vício que destrói vidas e segrega famílias, no tocante aos antecedentes, extrai-se que a F.A. de fls. 34/36 são prejudiciais, possui(em) conduta social e personalidade voltadas para a prática de crimes, tirando da prática delitiva o seu viver; as consequências do crime somente não foram piores em razão da rápida e célere atuação dos policiais; circunstâncias judiciais que autorizam a pena base acima do mínimo legal, sobremaneira diante da considerável quantidade de drogas apreendidas. Na segunda fase presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do CPB, visto que foi condenado(a) com sentença transitada em julgado para a defesa em data anterior à prática dos fatos em apuração (conforme certidão e F.A. devidamente juntados às fls.73/93). Na terceira fase, incabível a aplicação de causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei Federal n.º 11343/06, pois o réu não preenche seus requisitos, já que se trata de réu. Impossível outrossim a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, haja vista a incompatibilidade de tal instituto com as circunstâncias do delito. Certamente a substituição não foi criada pelo legislador para beneficiar traficante de drogas, crime grave que destrói as famílias e a sociedade, atingindo de forma relevante o bem jurídico saúde pública. Levando em linha de conta que o delito de tráfico de drogas é considerado assemelhado a crime hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei Federal n.º 8072/90). Com efeito, malgrado o óbice a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o crime de tráfico de drogas tenha sido afastado pela Resolução nº05/2012 do Senado Federal, cumpre ressaltar que, conforme já exaustivamente demonstrado, o acusado foi surpreendido com grande quantidade e diversidade de drogas, Então, no caso presente, a substituição é totalmente inviável, pois insuficiente para a reeducação e reinserção social do agente. Cada crime tem as suas características próprias, do mesmo modo, cada criminoso carrega consigo condições pessoais que lhe são intrínsecas. Neste sentido, a necessidade de individualizar as penas, o que significa, genericamente, adequar a reprimenda penal ao crime efetivamente praticado, bem como ao seu autor. Efetivamente, há que se ponderar que os dispositivos constitucionais devem ser interpretados de maneira a serem conjugados (ponderação de princípios), coexistindo harmonicamente uns com os outros e, portanto, malgrado a individualização da pena ser princípio constitucional (art. 5º, XLVI, CF), o combate aos crimes hediondos e aos crimes a eles equiparados também o é, porquanto elencado no rol dos direitos e garantias individuais do artigo 5º da Constituição Federal (art. 5º, XLIII). Por esse raciocínio, penas alternativas não devem ser aplicadas a casos como os dos autos, em vista da hediondez por equiparação do crime, que recomenda maior rigor na reprimenda. Cabe citar parte da fundamentação lançada no v. acórdão proferido nos autos de Apelação nº 0079886-20.2008.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho: "No que diz respeito a substituição da pena corporal

por restritivas de direitos, apesar da recente Resolução nº5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou suspensa a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a mesma não seria possível no presente diante das circunstâncias do caso concreto, pois não se mostra medida suficiente e adequada. Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. O que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, III do Código Penal). Os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal são cumulativos, devendo estar integralmente presentes para que seja concedida a substituição. Dessa forma, ante a não observância dos requisitos cumulativos dispostos no artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena é inadmissível." Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acompanhando de perto tal caminho de vedação da substituição da pena nos casos como o epigrafado: "Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou" (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011). Pelos mesmos motivos, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer a fixação de regime penitenciário fechado para inicial cumprimento da pena. O delito de tráfico de drogas é de extrema gravidade, causando perturbações de ordem social, econômicas e referentes à saúde, cenário que impõe maior rigor no tratamento penal, de modo que se o condenado por tráfico não for severamente punido sentir-se-á verdadeiramente impune e, assim, encontrará os mesmos estímulos para manter a prática de tais crimes. Por derradeiro, INVÍAVEL a concessão do direito de recorrer em liberdade ao(s) acusado(s) seja pela primariedade, seja pelos bons antecedentes, pois tratando-se de delito de tráfico de drogas seria uma contradição dar liberdade para apelado que em toda a persecução penal ficou recolhido, a teor do que dispõe o artigo 44 da Lei Federal nº 11.343 de 2006, cumulado com artigo 5º, incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal. Obtempere-se ainda que, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme consta nos autos, necessária a manutenção da prisão para evitar a continuidade do tráfico pelo acusado. Aliás, este o entendimento da abalizada doutrina de Renato Marcão, comentando o artigo em que se baseia o apelante, onde se lê que "subsistindo os requisitos da prisão preventiva, não tem direito à interposição de recurso em liberdade o réu condenado que fora mantido preso durante o processo, como é intuitivo" (Tóxicos, Lei 11.343/2006. 9ª ed. São Paulo. Saraiva: 2014, p. 328) No mesmo trilhar o entendimento da jurisprudência pátria: "Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo" (STF HC 115.462/RR 2ª T. Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 09/04/2013, DJE 075 de 23/04/2013) No mesmo trilhar: "Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade" (STF HC 107.796/MS 1ª T. Rel. Ministro Luiz Fux j 13/03/2012, DJE 077 de 20/04/2012) Requeremos ainda a perda dos bens e dinheiros apreendidos em favor da UNIÃO, caso algum valor tenha sido apreendido, tudo dos nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b" do CPB e artigo 63, §1º da Lei 11.343/06. Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu representante que esta subscreve, requer a PROCEDÊNCIA da presente ação penal para CONDENACÃO do(s) réu(s) como incursos nos artigos fixados na denúncia. ". Dada a palavra à Defesa,

as alegações finais foram colhidas pelo sistema de gravação audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença: "Vistos. ELTON LUIZ DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porquanto, de acordo com a acusação, no dia 25 de agosto de 2022, às 10h10min, no cruzamento entre a rua Prof. Paulo Lázaro Mendes Ferreira e a rua 04, Jardim Micali, nesta cidade e comarca de Taquaritinga/SP, o acusado trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 29 (vinte e nove) unidades de crack, com peso líquido de 6,91g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Oferecida a denúncia, o acusado foi notificado (fl. 137) e apresentou defesa prévia (fl. 142). A denúncia foi recebida (fls. 143/144) e o acusado foi citado pessoalmente (fl. 167). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, seguindo-se o interrogatório do réu. Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado, alegando a fragilidade do contexto probatório. É, em síntese, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 56/57), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 58/59), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 60/61) e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo nº 279.343/2022 (fls. 116/118), que atestou a presença da substância cocaína. A autoria é certa e repousa sobre o acusado. Vejamos. O réu Elton da Silva, quando interrogado pela Autoridade Policial, declarou que pretendia fazer uso de uma pedra de crack, quando foi abordado pela Polícia Militar. Declarou que tentou se evadir porque trazia consigo uma pedra de crack. Alegou que a latinha encontrada pelos policiais, que continha porções da mesma droga, não lhe pertencia (fl. 06). Interrogado em juízo, Elton novamente negou a imputação. Disse que foi até o local dos fatos para adquirir uma pedra de crack para seu consumo. Afirmou que, com a aproximação dos policiais, saiu correndo porque portava a porção de entorpecente. Negou a posse da lata apreendida pelos policiais. Contudo, as negativas apresentadas pelo acusado revelam-se frágeis e inconsistentes, sobretudo porque o remanescente da prova coligida nos autos é seguro em demonstrar a responsabilidade pela ação criminosa que lhe é imputada. Em Juízo, a testemunha Durval Jesus de Souza, policial militar, disse que realizava patrulhamento no Bairro Jardim Micalé, quando avistou o acusado. Narrou que, ao perceber a aproximação da viatura policial, o acusado demonstrou certo nervosismo. Por ser ele conhecido dos meios policiais, os milicianos resolveram realizar a abordagem e, ao emitirem ordem de parada ao acusado, este tentou se evadir do local. Relatou que fez o acompanhamento a pé e seu colega pela viatura e que, enquanto o acusado corria, dispensou uma lata. Declarou que pegou a embalagem e continuado o acompanhamento. Disse que seu parceiro conseguiu abordá-lo e que constatarem que na lata descartada havia 29 pedras de "crack". Relatou ter sido necessário o uso da força física para conter o acusado. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Sérgio Adriano Dellapina. A testemunha declarou, ainda, que o réu estava acompanhado de outra pessoa, a qual permaneceu parada, enquanto o réu tentou se evadir. Disse que na posse do outro indivíduo não havia nada de ilícito. Os testemunhos dos policiais, desse modo, apontam a autoria do crime, de forma que o acusado trazia consigo substância entorpecente destinada ao fornecimento para terceiros. Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, no tocante aos depoimentos de milicianos, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador. O testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Nesse sentido: "A prova testemunhal obtida por depoimento de

agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC – 2.^a T., rel. Min. Maurício Correa, DJU 13/12/1996); "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF – HC n.º 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846); e "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP – ApCrim. n.º 186.858-3 – 1.^a Câ. Criminal, Rel. Des. Jarbas Mazzoni, j. 18/12/1995). Com efeito, o conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o acusado, notadamente a quantidade dos entorpecentes (29 vinte e nove unidades de crack, com peso líquido de 6,91g) – incompatível com o consumo pessoal –, demonstra que o réu trazia a droga para o comércio ilícito. Destaca-se, ainda, que os entorpecentes encontravam-se individualmente embalados e prontos para a venda. Além disso, ao avistar a guarnição policial, o acusado tentou se evadir, tudo a demonstrar que, de fato, ele transportava a droga para o fim de tráfico. Cite-se, aqui, lição de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, no caso dando conta de que, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. "Prova Penal", 2.^a ed., RT, 2004, item 5, pág. 96). Noutras palavras, prescindível a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o réu, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (*praesumptiones hominis*) ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano, conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência (JOSÉ FREDERICO MARQUES, *Elementos de Direito Processual Penal*, 1.^a ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, *Código de Processo Penal Comentado*, 10.^a ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; STF, 2.^a T., HC 70.344/RJ, rel. Min. PAULO BROSSARD, RTJ, 149/521; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). "3. A força instrutória dos indícios é bastante para a elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si própria, o que não é apenas o caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de índole condenatória, quando não contrariados por contraindícios ou por prova direta. Doutrina: MALATESTA, Nicola Framarino dei. *A lógica das provas em matéria criminal*. Trad. J. Alves de Sá. Campinas: Servanda Editora, 2009, p. 236; LEONE, Giovanni. *Trattato di Diritto Processuale Penale*. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162; PEDROSO, Fernando de Almeida. *Prova penal: doutrina e jurisprudência*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 90- 91. Precedentes: AP 481, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011; HC n.º 111.666, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012; HC 96062, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009" (STF, HC 97781/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Ministro LUIZ FUX). Por outro lado, as razões apresentadas pela Defesa não afastam os relatos das testemunhas, de forma que a imputação se encontra satisfatoriamente demonstrada. A tese sustentada

pela defesa, portanto, de que os entorpecentes apreendidos no local descrito na denúncia não pertenciam ao acusado, restou insubsistente, uma vez que todo o contexto probatório aponta para a autoria do delito de tráfico por parte de Elton. As provas nos autos afastam, pois, a pretensão formulada pela Douta Defesa no sentido de que faltam suficientes elementos para motivar a condenação, porquanto a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor. Com estes fundamentos, passo a individualizar as penas. Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que acusado ostenta antecedente criminal, conforme se depreende dos autos (fls. 73/93), pois possui condenação definitiva anterior proferida no processo nº 0010942-68.2009.8.26.0619. Além disso, cumpre destacar que o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 29 pedras de crack, substância esta que apresenta altíssima lesividade à estrutura orgânica da pessoa e que detém maior e mais rápido grau de dependência, tornando mínimas as chances de recuperação do viciado. Destaco que o uso do crack está intimamente ligado à prática de crimes, uma vez que causa potente dependência psíquica, o que frequentemente leva o usuário que não tem capacidade monetária para custear o vício à prática de delitos, para que possa obter a droga. Assim, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/3, em razão da quantidade e natureza das substâncias apreendidas, bem como dos antecedentes criminais do acusado. Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente específico, pois ostenta condenação definitiva anterior em razão da prática de outro crime de tráfico de drogas (processo n.º 0009108-25.2012.8.26.0619 - fl. 69). Assim, com fulcro no artigo 61, I, do Código Penal, aumento a pena em 1/6. Não há atenuantes. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Nesse sentido, não se faz possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, posto que o acusado é reincidente específico, conforme certidão acostada autos (processo n.º 0009108-25.2012.8.26.0619 - fl. 69). A propósito, não há óbice em considerar a reincidência como circunstância agravante na segunda fase de dosimetria da pena, bem como para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem que se configure bis in idem, pois tal instituto possui finalidade jurídico-legal distinta em cada etapa de aplicação da pena, conforme expressa previsão legal (STJ, Habeas Corpus nº 236.982 /SP, 5ª Turma, Ministra Marilza Maynard, j. 04/06/2013). Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista a reincidência específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 33 do CP). Isso posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ELTON LUIZ DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Incogitável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a pena fixada supera o limite de 04 anos (art. 44, I, do CP) e porque o acusado é reincidente específico (artigo 44, § 3º do CP). Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois a pena aplicada é elevada, o que poderá fazer com que, em liberdade, o réu tente frustrar a aplicação da lei. A prisão é necessária, ainda, para preservação da ordem pública, porque restou comprovado que o réu faz do tráfico um meio de vida, razão pela qual apenas o encarceramento fará com que cessem as práticas criminosas. Ademais, o crime de tráfico de drogas é um delito de grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao sentenciado, tendo em vista que a indicação de defensor dativo faz presumir a insuficiência de recursos financeiros. Anote-se. Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, observando os termos do Convênio de Assistência Judiciária. A

certidão de honorários, uma vez assinada digitalmente, encontrar-se-á disponível no Portal do Tribunal de Justiça para impressão, independentemente de nova intimação. Incinere-se a droga apreendida, nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/06, ficando comprovação nos autos. Após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral, o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), e encaminhe-se cópia da sentença ou eventual acórdão às vítimas (art. 399 da NSCGJ e art. 201, § 2º do CPP). Oportunamente, arquivem-se os autos, com as movimentações de praxe (SAJ). Sentença publicada em audiência, sendo apresentada às partes pela mesma plataforma digital e lida pelo magistrado ao acusado. Saem os presentes intimados". Na sequência, o defensor interpôs recurso de apelação, sendo que o Ministério Público renunciou ao direito de recorrer. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Homologo a renúncia recursal ministerial. Recebo o recurso interposto, saindo a defensora intimada do prazo para apresentação das razões recursais. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões de recurso (CPP, art. 600). Após, observadas as cautelas de praxe, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção Criminal, com as nossas homenagens aos seus ilustres integrantes. Saem os presentes intimados." Anoto que, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, editado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, procedi a importação do arquivo de gravação desta audiência para o Sistema Informatizado SAJ. Ao final, o MM. Juiz agradeceu a todos os envolvidos na participação da presente teleaudiência. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Valeria Storino, digitei e atuei conjuntamente para realização do ato e certifico e dou fé da veracidade deste termo, cientes e intimadas as partes. Em cumprimento das NSCGJ, art. 1269, § 1º, o presente termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e cientificados os participantes.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA